

1500089-73.2022.8.26.0067

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PEQUENA QUANTIDADE - INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância." (STF; HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Rui Barbosa, 111, Centro, Borborema - SP - cep 14955-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500089-73.2022.8.26.0067

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3019041/2022 - Delegacia de Polícia de Borborema, 23587490 - Delegacia de Polícia de Borborema

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DAVID WESLEY PEREIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 10 de agosto de 2022, às 10:00h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Borborema, Comarca de Borborema, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, e também presente na Sala de Audiências do Juizado Especial Criminal da Comarca de Borboremaem, através de videoconferência criada no software "Microsoft Teams", em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM 2564/2020, e mediante prévia concordância das partes e do(s) advogado(s) para a realização do ato de forma virtual, foi aberta a audiência híbrida de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. foi aberta a audiência virtual de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, ficando consignado que as partes foram intimadas via e-mail, sendo anexado o link de acesso à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão do Promotor de Justiça, Dr. José Francisco Ferrari Júnior, Ausente o réu David Wesley Pereira, presente advogado(a) Dr(a). Juliana Aparecida Artung Catelan, da(s) testemunha(s) arroladas na denuncia. Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao Dr. Procurador do réu para oferecimento de

resposta à acusação, nos termos do art. 81 da Lei 9.099/95, que nada alegou. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a decisão: "Vistos. Havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA contra David Wesley Pereira. Anote-se. Comunique-se". Em seguida, pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis 11.419/06 e 11.719/08, o MM. Juiz inquiriu 02 testemunhas arroladas pela acusação. Antes de ser(em) ouvido(s), os participantes exibiram o(s) documento(s) de identificação pessoal com foto, para a gravação, apontando o documento para a câmera, com a finalidade de ser efetuada a qualificação das partes, nos termos do art. 147 das NSCGJ. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do parágrafo 2º, do artigo 405, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e 886/04 do Conselho Superior de Magistratura, sendo desnecessária a transcrição.

Encerrada a instrução, foi dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça para apresentação de alegações finais, que se manifestou oralmente, com gravação em mídia.

Dada a palavra ao Dr. Procurador do acusado, foi dito: " Trata-se de processo crime promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de DAVID WESLEY PEREIRA, o qual está sendo processado como incurso no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, pois, na ocasião dos fatos, trazia consigo droga, consistente em 6,51 g (seis gramas e cinquenta e um centigramas) de "maconha", para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De acordo com a denúncia, policiais militares encontravam-se em patrulhamento pelas ruas da cidade, quando avistaram David e outros três indivíduos, os quais, ao avistarem a viatura, teriam se dispersado, motivando a abordagem. Dessa forma, ao ser revistado, teria sido localizada uma porção de maconha. A denúncia foi protocolada em 06 de abril de 2022, o acusado foi regularmente citado, sendo-lhe nomeado defensor, participando da instrução e garantindo o contraditório. Pela análise dos autos, tem-se que o pedido inicial merece ser julgado improcedente. Ouvido na fase policial, o acusado confessou a prática do delito, afirmando ser usuário de entorpecentes desde os 14 anos de idade. No entanto, não há que se falar em prática de ilícito penal pelo acusado, visto que a conduta referida é atípica, pois a conduta narrada nos autos não violou expressamente o objeto jurídico tutelado, no caso, a saúde pública, ao ponto de ensejar a intervenção do Estado, principalmente pela ínfima quantidade de entorpecentes apreendida, sendo, ainda, de uma única espécie: maconha. Deste modo, enseja-se a aplicação do princípio da insignificância, pela atipicidade da conduta e pela falta de tipicidade da matéria. Além de que o direito penal é a última razão que deve ser utilizada e não deve ser usado para resolver pequenos problemas, pois entre as normas do direito, o direito penal é o que deve ser utilizado apenas em último caso. O artigo 28 da Lei 11.343/2006 contraria o princípio da intimidade e da vida privada, esculpido no artigo 5º, X, da Constituição Federal, direito fundamental do acusado, pois a conduta de portar drogas para uso próprio não implica lesividade, princípio básico do direito penal, uma vez que não causa lesão a bens jurídicos alheios. E como o Direito Penal não se presta a punir a auto lesão, não há que se falar na ocorrência do crime, pois não há sequer no presente caso, ameaça de lesão a um bem jurídico penalmente relevante. Portanto, o acusado deve ser absolvido por atipicidade da conduta. Caso o mesmo venha a ser condenado, requer a aplicação das reprimendas em seu mínimo legal, qual seja, a de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei n.º 11.343/2006.

A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Relatório dispensado.

DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a

análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha PAULO HENRIQUE DE SOUZA, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pela Vila Cristina, local conhecido pelo uso e tráfico de drogas, quando visualizaram quatro jovens caminhando pela rua, eles avistaram a viatura e se dispersaram, então resolveram abordá-los. O réu, David, vulgo Majin Bu, dispensou uma porção de maconha e confirmou que estava trazendo a porção para uso próprio com o demais.

A testemunha LEONARDO LIMA MESSIAS, policial militar, disse que estava com o parceiro em patrulhamento, quando avistaram um grupo de jovens andando, que se dispersaram quando viram a viatura, por isso abordaram eles. Um deles dispensou algo no chão, fizeram revista em todos e não encontraram nada, mas o Wesley tinha dispensado uma substância parecida com maconha, questionaram ele e ele afirmou que era maconha e destinada para uso próprio.

Em sede policial, o acusado havia dito que “é usuário desde os 14 (catorze anos de idade). Que no dia dos fatos, foi abordado pela polícia, mas que teria jogado no chão uma porção de maconha. Que neste dia estava com as pessoas de ANDERSON, DIEGO E LAÉRCIO. Que eles também são usuários de drogas. Que comprou a droga em Ibitinga, de pessoa desconhecida. Que comprou a droga em uma festa. Que pagou o valor de R\$ 50,00 (cinquenta) reais pela droga, mas porque comprou um pedaço grande para usar em sua casa. Que nunca ficou internado em clínicas de recuperação.”

Pois bem.

Entendo que não há presença de tipicidade material no presente caso.

Isso porque a quantidade de entorpecentes encontrada com o denunciado foi ínfima (uma porção de maconha – 6,51 gramas), o que não representa lesividade ao bem jurídico tutelado (saúde pública).

Além disso, o denunciado é primário e as circunstâncias do fato não indicam periculosidade social da ação, de modo que passível a incidência do princípio da insignificância.

Destaco, à luz do princípio da insignificância, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO. Posse de drogas para consumo pessoal. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Possibilidade. Apreensão de ínfima quantidade de droga que não revela ofensividade penal. Reconhecimento excepcional do princípio da insignificância. Conduta do agente que não gera lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a saúde pública. Fato materialmente atípico, apesar de apresentar tipicidade formal. Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Criminal 1500905-30.2018.8.26.0541; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021).

“Habeas corpus. 2. Posse de 1 (um grama) de maconha. 3. Condenação à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 4. Pedido de absolvição. Atipicidade material. 5. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela concessão da ordem. 7. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade material.” (STF; HC 127573, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PEQUENA QUANTIDADE – INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância.” (STF; HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019).

Outrossim, o princípio da alteridade não permite que se criminalize condutas subjetivas, que não possuam o poder de ofender bens jurídicos de terceiros ou da coletividade. No caso em tela, tem-se que somente a saúde do próprio réu foi posta

em risco.

Por fim, ressalte-se decisões atuais do STF e do STJ, respectivamente, que não mais consideram as condenações pelo disposto no artigo 28 da Lei Antidrogas para fins de reincidência:

“Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, “porte de droga para consumo pessoal”, para fins de reincidência.”

(STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 - Info 1048).

“Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.” (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Em suma, haveria um crime “despenalizado”, com penas que não possibilitam a prisão, incapaz de gerar reincidência.

Ante o EXPOSTO, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, o acusado DAVID WESLEY PEREIRA da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia (artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06). Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.”

Pela defesa foi manifestado o desejo de não apelar da r. Sentença. Pelo Dr. Promotor de Justiça foi manifestado o desejo de apelar da r. Sentença. Tendo o MM.Juiz recebido nesta data o recurso de apelação e, determinando a abertura de vista ao mesmo para apresentação de razões de apelação. Todos os depoimentos foram colhidos por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e a gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal do e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível no respectivo Termo de Audiência. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1270, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença proferida e publicada em audiência. Nada mais. Eu, Cesar Floriano de Oliveira, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):

Vítima: